

1518636-03.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518636-03.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518636-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO NERING NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JOÃO NERING NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.155, § 4º, I, do Código Penal; no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; no art.12 da Lei nº 10.826/2003 e no art.21, "caput", da Lei das Contravenções Penais, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Segundo apurado, em data incerta, entre meados de julho e 03 de agosto de 2021, na Rua Rifaina nº 126, casa 2, Perdizes, nesta Capital, o acusado, subtraiu, para si, com rompimento de obstáculo, 71 (setenta e um) perfumes e cosméticos em geral; um televisor marca "LG"; dois "notebooks" marcas "Samsung" e "Dell"; um toca-discos; 50 (cinquenta) discos de vinil; a 1ª edição de "Mafalda"; dois aparelhos auditivos marca "Somex"; 24 (vinte e quatro) DVDs; um secador de cabelos; uma chapinha; um roteador de celular marca "Chromecash B"; quatro ferramentas diversas; cinco relógios de pulso; dois colares, um par de brincos de ouro; uma parafusadeira elétrica marca "Bosch"; 10 (dez) painéis e documentos pessoais, tudo pertencente à vítima E.C.B.da S.

Consta, ainda, que no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 14h45min, na Rua Rifaina nº 126, casa 2, Perdizes, nesta Capital, o indiciado, tinha em depósito, para fim de tráfico, 10 tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É dos autos, outrossim, que nas mesmas condições de tempo e local, João Nering Neto, possuía uma munição calibre .32, marca "CBC", de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local, o acusado praticou vias de fato contra a referida vítima E.C.B.da S.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado e apresentou resposta à

acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima, dois policiais, uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado. (fls. 240/241 e 272/273).

As testemunhas Eliane e Leandro, esta apenas da Defesa do acusado, não compareceram à audiência e as partes desistiram de suas oitivas, o que foi devidamente homologado.

Encerrada a instrução criminal em suas alegações, o Ministério Público buscou a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado incurso nos artigos 155, "caput", do Código Penal; 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; 12 da Lei nº 10.826/2003 e 21, "caput", da Lei das Contravenções Penais, em concurso material, pugnando pelo afastamento da qualificadora do crime de furto, já que não foi comprovada nos autos. (fls. 285/292).

Já a Defesa requereu, com relação ao crime de furto, a absolvição do réu por insuficiência probatória ou em caso de condenação sua desclassificação para o crime previsto no art. 345 do mesmo diploma legal, além do reconhecimento da confissão espontânea do acusado. Quantos aos demais crimes também pugnou pela absolvição do acusado, afirmando, em suma, que as drogas não foram encontradas na casa do réu e sim em outra residência que fica ao lado, e que na verdade pertenciam a um inquilino de nome André e que as munições na verdade seriam da própria vítima. Por fim alegou que não houve a prática de vias de fato a vítima.

Em caso de eventual condenação, pugnou pelo reconhecimento da confissão do réu quanto ao crime de furto, pela aplicação do disposto no art. 33, §4º da lei 11.343/06; pela fixação de regime de pena diverso do fechado, considerando, sobretudo o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Pleiteou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e pelo direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista das provas existentes nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade dos delitos, restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão e de reconhecimento dos objetos subtraídos, laudo de constatação de substância entorpecente e laudo de exame químico toxicológico positivo para maconha, (fls.147/149), laudo da munição apreendida (fls.259/262), dos demais objetos apreendidos (fls.263/264, . 265/268, 269/271), laudo do local dos fatos (fls.276/281), relatório final da autoridade policial, bem como pela robusta prova produzida na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é incontestada.

No que toca ao crime de furto, o próprio réu ao ser ouvido em juízo, disse que realmente, entrou na casa que alugava para a vítima e retirou de lá alguns de seus pertences.

É fato que afirmou, apenas em juízo, que fez isso pois a vítima estava lhe devendo quantia referente a contas do imóvel locado, contudo, sua versão não veio corroborada nos autos.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima E.C. B. da S., afirmou que era inquilina do réu e morava na casa ao lado de João.

Narrou que passou um período fora por conta do trabalho, sendo que, ao retornar, não encontrou seus pertences nem mesmo seus documentos pessoais e que a janela da residência que locava estava quebrada, mas não havia sinais de arrombamento nas portas. Em razão disso, acionou a polícia e decidiu mudar-se do local.

Ao tomar ciência de sua mudança, o réu João começou a jogar vários de seus pertences pessoais pela janela do segundo andar, proferindo palavras de baixo calão. Em seguida, passou a agredi-la, desferindo socos e pontapés. Visualizou seus bens subtraídos no interior da casa do réu, ocasião em que chamou a polícia para recuperá-los. Os policiais acabaram encontrando, no interior da residência de João, além de partes de seus objetos, entorpecentes. E ao ser interpelado pela polícia

sobre tudo o que fora encontrado na residência, o réu apenas dizia que ela estava com débitos pendentes. Por fim, relata que não conseguiu recuperar nem metade dos seus pertencentes, sofrendo um prejuízo de quase R\$ 100.000,00.

Os policiais que atenderam ao chamado da vítima, Heliézer Ramos de Azevedo e Rubem Alves Catulé de Almeida Neto, ao serem ouvidos em juízo, narraram que foram acionados, via COPOM, para atendimento de furto em residência. Ao chegarem encontraram com a vítima que era inquilina do réu e morava em uma das casas que havia no terreno que lhes informou que após ter passado um período fora por conta do trabalho, ao retornar, não encontrou seus pertences nem mesmo seus documentos pessoais e diante disso foi orientada a se dirigir à um distrito policial mais próximo e lavrar um boletim de ocorrência.

No fim da tarde, receberam novo chamado no mesmo local relatando que a mesma vítima estaria sendo agredida por seu vizinho. No local, a vítima relatou que logo que a polícia saiu do local, o réu passou a jogar seus objetos pessoais pela janela do segundo andar, proferindo palavras de baixo calão e em seguida, passou a agredi-la, desferindo socos e pontapés.

Diante disso, se dirigiram à residência do réu e vistoriaram o local, onde foram encontrados além de vários pertences reconhecidos pela vítima como sendo seus, entorpecentes, materiais para pesagem e embalagem das drogas e uma munição. Ao ser indagado sobre os objetos ali encontrados o réu negou ser proprietário das drogas e da munição e ainda que teria furtado bens da vítima.

Mauro Henrique da Silva Marques de Oliveira, após afirmar que era amigo do réu, relatou que a vítima alugava uma das casas de João e estava trazendo diversos problemas para o réu, possuindo desavenças em relação à conta de luz e que teria inclusive riscado um carro pertencente ao réu, em razão desses desentendimentos. Disse ainda, que não sabia de qualquer tipo de envolvimento do réu com o crime de tráfico de entorpecentes e ainda que casa do réu estava sem janelas devido à ocorrência de obras no local. Nada soube informar sobre agressões por parte do acusado contra a vítima.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela combativa Defesa do acusado, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu.

Isso porque ele mesmo confirmou ter se apoderado de alguns pertences da vítima que estavam no interior da residência por ela locada, fato que foi devidamente corroborado pelas declarações de E.C. e ainda pelos relatos dos policiais.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. O único interesse dela é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97. Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação

por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Por outro lado, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

De outra banda, inviável a desclassificação da conduta imputada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no art 345 do Código Penal, sobretudo porque a Defesa não logrou êxito em comprovar a suposta existência de débitos da vítima em favor do réu ou mesmo que ele achasse credor de alguma coisa de propriedade da vítima.

Veja-se que a única testemunha de Defesa, ouvida nestes autos, relatou apenas que sabia de problemas envolvendo a vítima e o réu, mas nada trouxe de concreto a este respeito.

Assim sendo, a alegação do acusado, trata-se de mera conjectura por ele engendrada com o fito de justificar a subtração perpetrada em desfavor da vítima.

Dessa forma, sem demonstração da existência de uma dívida e, portanto, da real ou supostamente legítima da pretensão, incabível a pretendida desclassificação, já que a tese de Defesa deve ser provada nos autos, não bastando a mera alegação do réu, como quer fazer crer o combativo defensor, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer..."

Neste sentido: " (...) nos moldes do art. 156, do CPP, de sorte que esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (Ap. Crim. 2009.004387-0-SC, 2ª C., rel. Salette Silva Sommariva, 22.04.2010, v.U).

A qualificadora do crime de furto, decorrente do rompimento de obstáculo, no entanto, como muito bem pontuado pelo membro do Parquet, não restou devidamente comprovada nos autos.

De fato, o laudo do local dos fatos, juntado a fls.276/281, apenas constatou que "havia peças de pratos, xícaras e canecas que foram lançadas ao piso da escadaria do acesso lateral entre o nível superior e inferior do terreno", nada havendo de concreto sobre eventual "rompimento de obstáculo" para a subtração, portanto, de rigor o afastamento desta e a desclassificação do delito para furto simples.

No que tange aos crimes de tráfico de entorpecentes e de porte de munição, mais uma vez, não obstante as alegações da Defesa, analisando as provas colhidas nos autos, há provas suficientes para a condenação do acusado.

É certo que o réu negou tais fatos, afirmando que encontrou a munição na residência da própria vítima e que apenas a recolheu para sua residência pois teve receio de que a Ellen também possuísse uma arma de fogo e que os entorpecentes, foram

encontrados em outra residência que também fora construída no mesmo terreno e estava alugada para um rapaz de nome André.

Essas afirmações, contudo, também não vieram corroboradas por outras provas. Em sentido oposto, os dois policiais foram firmes em afirmar que tanto as drogas como a munição estavam na residência do réu, e foram ali encontradas em razão de revista no intuito de se encontrar bens pertencentes a vítima.

Os depoimentos dos dois policiais foram ainda, corroborados pelas demais provas amealhadas aos autos, tais como auto de exibição e apreensão dos tabletes de maconha e da munição de fls. 22/24, laudo de constatação das substâncias entorpecentes, (fls.54/56), laudo de exame químico toxicológico positivo para maconha, (fls.147/149) e laudo de fls. 259/262 que concluiu pela potencialidade lesiva do cartucho apreendido.

Veja-se, ademais, que o acusado sequer arrolou André ou outras possíveis testemunhas para que eventualmente pudessem ser ouvidos para confirmar sua versão. Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou plenamente atestado que a droga encontrada no interior da residência do réu.

Ressalta-se, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas, ou seja, 10 tabletes de maconha, bem como os materiais que estavam no interior da residência ou seja, balanças, rolo de plástico filme, e sobretudo, um dichavador em material metálico (fls. 22/24), que conforme laudo de fls. 271 é "normalmente usado para "triturar", ervas" já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia, e portanto, também quanto a estes dois crimes, merece acolhimento a pretensão punitiva.

Por fim, no que tange à contravenção penal de vias de fato, que também foi rechaçada pelo réu, fato é que vítima tenha alegou em seu depoimento que o réu após jogar seus objetos pessoais pela janela do segundo andar (laudo do local dos fatos às fls. 276/281), proferindo palavras de baixo calão e em seguida, começou a agredi-la, com socos e pontapés e seus relatos, foram confirmados pela testemunha Eliane Martins Amadio, ouvida a fls. 13. É fato que o depoimento da testemunha não foi replicado em juízo, já que as partes desistiram de sua oitiva. No entanto, nada há nos autos para desacreditar do relato detalhado apresentado pela vítima e por tal testemunha, havendo prova suficiente e segura para se concluir que o réu efetivamente praticou as infrações penais contra ela.

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, se mostram suficientes para embasar a condenação do réu, também com relação a esta infração penal.

Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova material da contravenção penal de vias de fato não requer prova via laudo, pois não deixa vestígios, e a ausência de lesões corporais não desnatura o crime imputado.

Ademais, evidentemente, em crimes dessa espécie, que a palavra da vítima deve preponderar, pois não foi comprovada qualquer circunstância que pudesse demonstrar intenção da ofendida de prejudicar o réu.

Caracterizadas, portanto, as infrações penais supracitadas, passo a dosimetria da pena.

1) Do crime de furto, em sua forma simples:

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, de acordo com a certidão de fls.63. Assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação de pena deve-se considerar que o crime foi cometido em

situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, que em agosto de 2021, assolava o país e foi reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Assim sendo, a pena deve ser agravada em 1/6, chegando-se a 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020: “O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se

exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020) TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J.16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal – Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da

existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se. Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la".

Por outro lado, não há que se falar em confissão, já que o réu ao ser interrogado em juízo disse que se apoderou dos bens da vítima, para ser ressarcido de prejuízos decorrentes de contas advindas do imóvel por ele locado, negando assim a subtração. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

2)Do crime de tráfico de entorpecentes

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, de acordo com a certidão de fls.63. Assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, forçoso reconhecer a agravante decorrente da pandemia da COVID 19, pelos fundamentos acima expostos, e assim sendo a pena deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se a 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não obstante a primariedade do acusado, mostra-se incabível o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente em razão da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, ou seja, 10 tabletes de maconha, que para esta magistrada, demonstra que o acusado se dedica a atividade criminosa, principalmente em razão do valor econômico dos entorpecentes. Portanto, mantenho a pena acima fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena

3)Do crime de posse irregular de munição de arma de fogo

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, de acordo com a certidão de fls.63. Assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal de 01 ano de detenção e 10 dias multa.

Na segunda fase presente a agravante acima apontada, devendo a pena ser aumentada em 1/6, totalizando 01 ano, 02 meses de detenção e 11 dias-multa. Não há atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

4) Da contravenção penal de vias de fato

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, de acordo com a certidão de fls.63. Assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal de 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, diante da agravante da pandemia a pena deve ser aumentada em 1/6,

perfazendo 17 dias de prisão simples.

Ausentes, na próxima fase de aplicação de pena circunstâncias modificadoras.

Os crimes foram praticados na forma do disposto no art. 69, "caput", do Código Penal e assim sendo, diante do concurso material de delitos as penas deve ser somadas chegando-se a crimes, figura prevista no artigo 69 do Código Penal, devendo as penas serem somadas, perfazendo o total de 7 anos e 15 dias de pena privativa de liberdade, e 520 dias multa.

Assim, torno essa pena definitiva por inexistência de outras causas a se considerar.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu JOÃO NERING NETO como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal; no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 21, "caput", da Lei das Contravenções Penais, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 anos, 02 meses e 17 dias de pena privativa de liberdade, e 605 dias multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Considerando a quantidade de pena aplicada, e ainda a condenação pelo crime de trafico de entorpecentes, o regime inicial de cumprimento de pena é FECHADO para os delitos punidos com pena de reclusão, e o SEMIABERTO para os delitos apenados com detenção e prisão simples, nos termos disposto no Código Penal, ressaltando que a pena deve ser executada nos moldes estabelecidos pelo art. 76, do Código Penal. Não poderá recorrer desta em liberdade, seja porque foi condenado pela prática de 04 crimes, sendo um deles o trafico de entorpecentes, delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou, crime ainda, que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Outrossim, levando-se em conta a quantidade de pena aplicada, e a natureza dos delitos pelos quais foi condenado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, do Código Penal.

Deixo de computar o período de prisão provisória do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente em critério objetivo. Depende, também, do mérito do condenado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos parte da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Além disso, prevalecer o entendimento de que a lei não determina o cômputo do período de prisão provisória como meio de antecipar a progressão de regime, mas como critério para fixar o regime inicial de cumprimento da pena, aquele que sob custódia esteve no curso do processo poderá ser agraciado com progressão, na fase de execução criminal, com novo desconto do período já considerado para beneficiá-lo com regime menos gravoso na sentença condenatória.

Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2º do CPP, a teor do que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.

O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2º do Código Penal.

No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2º. e 3º do Código Penal.

É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.

A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.º no art. 387 do CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2º, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.º. Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que inclui o regime, de maneira correta." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 805/806).

Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP." (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

"HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a fixação do regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)".(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal.

Por fim, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva para o acusado, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se o cálculo da pena de multa aplicada, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada do cálculo aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Encaminhe-se a munição apreendida ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

Quanto aos entorpecentes, determino a incineração inclusive das amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Custas na forma da lei. . Deixo de isentar o réu do pagamento da referida taxa, já que não compete a este juízo esta decisão, ainda mais porque, não há os autos qualquer prova da condição econômica do réu, consoante entendimento consolidado como se demonstra na Apelação Criminal nº 1504000-37.2018.8.26.0228, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA